

1502202-63.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO DE MORAES GOMES

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

CRISTIANO DE MORAES GOMES, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502202-63.2021.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502202-63.2021.8.26.0510 - 2021/000445

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO DE MORAES GOMES

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

CRISTIANO DE MORAES GOMES, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 05 de julho de 2021, por volta das 19:39 horas, na Rua M-10, com a Avenida M-21, Jardim Independência, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 76 (setenta e seis) invólucros contendo a substância entorpecente denominada cocaína, na forma de crack, totalizando peso líquido de 20,44 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21 e laudo de constatação de fls. 23/25, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 19 de outubro de 2021. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, inviabilizando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da recidiva, devendo ser a pena cumprida em regime prisional inicial fechado, operando-se, por fim, o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado.

Já o ilustre Defensor Público sustentando insuficiente a prova produzida, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito irrogado para a infração prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Em caso de condenação, requereu seja fixada a pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, além da fixação de regime prisional inicial aberto.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 125/127, com resultado positivo para cocaína.

Controverte-se sobre a posse da totalidade do entorpecente apreendido e sua destinação mercantil.

Ouvido em juízo, o acusado afirmou que, após conseguir a quantia de trinta e cinco reais, com a limpeza de calçadas, sendo morador de rua, dirigiu-se ao local indicado na denúncia, ponto de venda de entorpecente, onde adquiriu com dois rapazes três porções de crack. Quando se afastavam, foi abordado por policiais militares, enquanto que aqueles dois outros indivíduos empreenderam fuga.

Acrescentou que as porções de crack que tinha consigo foram apreendidas, negando tivesse qualquer outro numerário em seu poder, sendo que posteriormente os policiais militares se deslocaram até uma esquina próxima onde teriam apreendido o restante do entorpecente exibido à d. Autoridade Policial.

Todavia, a versão deduzida pelo acusado, foi contrariada pela prova produzida.

De fato, os Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, reiterando em juízo o que inicialmente exposto, de forma coerente e minudente, afirmaram que na ocasião estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de intenso tráfico de entorpecentes, quando avistaram o acusado seguindo em direção a dois indivíduos. Quando ele notou a

presença da guarnição, recuou, por isto acabou sendo abordado, momento em que aqueles indivíduos se afastaram. Com o acusado, no bolso da blusa, foram encontradas cinquenta e seis porções de crack. E porque apresentava ele dificuldade de fala, quando indagado sobre o entorpecente, verificou-se que mantinha no interior da boca outras vinte porções da mesma substância entorpecente, por isto que conduzido ao Plantão Policial, não sem alguma resistência.

Como se tem consagrado, à minguada de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais envolvidos na diligência. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829). Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372). E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Como se vê, não apenas a apreensão de significativa quantidade de porções de crack em poder do acusado, em local conhecido pelo comércio ilícito, mas também as circunstâncias em que se deu esta apreensão, no momento em que ele se aproximava de dois indivíduos, possivelmente usuários, mantendo ainda vinte porções de crack no interior da boca, revelam inequivocamente o propósito mercantil.

Deste modo, os elementos probatórios possibilitam seguro juízo de convicção sobre a imputação inicial, sendo incontornável o acolhimento da pretensão acusatória.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida e dada a alegada situação de drogadição, possível seja a pena base fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena base deve ser agravada, entretanto, em 1/6 (um sexto), por conta da recidiva (fls. 94), totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Por fim, diante do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, a recidiva também afasta objetivamente a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, caput" Lei nº 11.343/06 e artigo 61, inciso I, do Código Penal, CONDENO o acusado CRISTIANO DE MORAES GOMES à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, deve ser considerada a recidiva e também a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando

constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispondo o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, prolanada do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênua, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênua, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interdita a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descurar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras. Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, potencializados pela sentença condenatória, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

A propósito: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1). E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inoccorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008). E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico

ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA